

刑法
No230

予備独自問題R4-12

(配点: 2)

月 日

月 日

遺棄の罪に関する次の【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

遺棄とは、場所的離隔を生じさせることにより、要扶助者を保護のない状態に置くことをいうところ、遺棄罪（刑法第217条）の「遺棄」は、要扶助者を移動させる行為（移置）のみに限られるが、保護責任者遺棄等罪（同法第218条）の「遺棄」は、移置のほか、置き去りのように、要扶助者の移動を伴わず、行為者自身が移動することで要扶助者との場所的離隔を生じさせる行為を含む。同罪の「不保護」は、場所的離隔を伴わずに、要扶助者の生存に必要な保護を行わないことをいう。また、同罪の「保護する責任」と不真正不作为犯における作為義務は一致する。

【記 述】

ア. この【見解】によれば、保護責任を有しない者が置き去り行為をした場合、刑法第217条で処罰することが可能である。

イ. この【見解】に対しては、不真正不作为犯において、作為との同価値性を基礎付ける要件にすぎないはずの作為義務が、加重処罰の要件である保護責任と同視されており、妥当でないとの批判が可能である。

ウ. この【見解】によれば、保護責任を有する者が要扶助者から離れ、要扶助者を保護のない状況に置いた場合、刑法第218条で処罰することが可能である。

エ. この【見解】に対しては、隣り合った条文で用いられている同一の文言の解釈が異なることとなり、妥当でないとの批判が可能である。

オ. この【見解】によれば、保護責任を有する者の行為によって要扶助者の生命に対する危険が具体化した場合に限り、刑法第218条で処罰することが可能である。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ オ 5. ウ エ

No230	遺棄の罪		正答率
予備R4-12	正解	2	84%

ア 誤っている

本記述は、【見解】によれば、保護責任を有しない者が置き去り行為をした場合、217条で処罰することが可能であるとしている点で、誤っている。

【見解】は、遺棄罪（217条）の「遺棄」は、要扶助者を移動させる行為（移置）のみに限られるとしているため、置き去り行為は「遺棄」に含まれない。したがって、【見解】によれば、保護責任を有しない者が置き去り行為をした場合、217条で処罰することはできない。

イ 正しい

【見解】は、保護責任者遺棄等罪（218条）の「保護する責任」と不真正不作为犯における作為義務は一致するとしている。よって、この【見解】に対しては、不真正不作为犯において、作為との同価値性を基礎付ける要件にすぎないはずの作為義務が、加重処罰の要件である保護責任と同視されており、妥当でないとの批判が可能である。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

【見解】は、保護責任者遺棄等罪（218条）の「遺棄」は、移置のほか、置き去りのように、要扶助者の移動を伴わず、行為者自身が移動することで要扶助者との場所的離隔を生じさせる行為を含むとしている。よって、この【見解】によれば、保護責任を有する者が要扶助者から離れ、要扶助者を保護のない状況に置いた場合、218条で処罰することが可能である。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

【見解】は、遺棄罪（217条）の「遺棄」は移置のみに限るのに対し、保護責任者遺棄等罪（218条）の「遺棄」は移置のほか、置き去りを含むとしている。よって、この【見解】に対しては、隣り合った条文で用いられている同一の文言の解釈が異なることとなり、妥当でないとの批判が可能である。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

本記述は、【見解】によれば、保護責任を有する者の行為によって要扶助者の生命に対する危険が具体化した場合に限り、218条で処罰することが可能であるとしている点で、誤っている。

①遺棄罪の罪質について、生命・身体に対する危険犯と解する見解と、生命に対する危険犯と解する見解が対立している。また、②遺棄罪を抽象的危険犯と解する見解と、具体的危険犯とする見解が対立している。遺棄罪を生命（①）に対する具体的危険犯（②）と解すれば、要扶助者の生命に対する危険が具体化した場合に限って処罰されると解することが可能とも思えるが、【見解】が上記①②につきどのように解しているかは明らかでない。したがって、この【見解】によっても、必ずしも本記述のように解することになるわけではない。なお、判例は【見解】と同様の立場である（最判昭34.7.24）が、生命・身体に対する抽象的危険犯であると解しているといわれる（大判大4.5.21）。

以上により、誤っている記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。